

1500292-21.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... pela prática de furto, roubo e tráfico devem ser consideradas para a fixação da pena e do regime inicial de resgate. A Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo não fornecimento das imagens do circuito do presídio; o réu afirmou veementemente a inocência e que isso poderia ser comprovado pelas filmagens; inexistência de prova da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-21.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-21.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2032459/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 16938832 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 17/22/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2032459 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FELIPE DA SILVA FERRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

JEFFERSON FELIPE DA SILVA FERRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 16 horas, no alojamento B, da ala de progressão, da Penitenciária "Valentim Alves da Silva", situada na Rodovia Mamede Barreto (SP-349), Km 36, na cidade de Álvaro de Carvalho, comarca de Garça, mantinha em depósito, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo maconha (40,30 gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o réu cumpre pena privativa de liberdade na referida unidade prisional. Na data dos fatos, agentes penitenciários realizavam procedimento de

revista geral na ala de progressão da unidade prisional e, no momento em que vistoriavam o alojamento B, localizaram na cama B-69, oculto em meio aos pertencentes do réu, os entorpecentes descritos, dos quais o réu informalmente assumiu a propriedade.

É da denúncia que as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes se destinavam à comercialização, porque a quantidade encontrada é incompatível com a condição de usuário e estava em porções individuais prontas para venda dentro da penitenciária.

Auto de apreensão à pág. 9 e laudo às págs. 12/16.

Denúncia oferecida aos 11 de março de 2022 (págs. 32/33). O réu foi notificado (pág. 38) e apresentou defesa prévia (págs. 45/48).

Aos 30 de maio de 2022, recebida a denúncia e determinada a instrução (págs. 53/54). O réu foi citado (pág. 99).

Folha e certidão de antecedentes às págs. 108/121.

Inquiridas testemunhas e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações sobre a dosimetria da pena. Sustentou que as condenações transitadas em julgado pela prática de furto, roubo e tráfico devem ser consideradas para a fixação da pena e do regime inicial de resgate. A Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo não fornecimento das imagens do circuito do presídio; o réu afirmou veementemente a inocência e que isso poderia ser comprovado pelas filmagens; inexistência de prova da materialidade, por ter sido retirada amostra para realização de contraperícia, cujo resultado não foi anexado aos autos, não se tendo certeza de que o produto examinado era efetivamente maconha. Que há dúvidas sobre a autoria do crime, o suposto entorpecente poderia ter sido implantando nos pertences do acusado por qualquer outra pessoa presente no local, outro detento, fato bastante corriqueiro. Além disso, a quantidade da suposta droga, poderia estar sendo guardada para consumo pessoal, amoldando-se o caso ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, que é o pedido subsidiário de desclassificação (págs. 139/140).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalto que não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Note-se que, em atendimento ao pedido da Defesa para juntada de imagens captadas por câmeras existentes na unidade prisional, o Diretor da penitenciária informou que o equipamento de armazenamento possui capacidade limitada para manter as imagens apenas por alguns dias, e que, por não ter sido identificada nenhuma situação atípica, não foram extraídas imagens para armazenamento (págs. 61/63 e 83).

Há se ponderar, portanto, que a impossibilidade de produção de prova não equivale a obstaculizar sua produção.

Também em atenção ao pedido da Defesa, Chefe de Equipe da Polícia Técnico-Científica informou que não houve exame preliminar e sim o laudo definitivo (págs. 45/48, 53/54 e 148).

Já outros aspectos entrosam-se com o mérito propriamente dito.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e o elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 9), laudo (págs. 12/16) e prova oral.

De fato, no material apreendido foi detectada substância de uso proscrito no Brasil (Tetrahidrocannabinol - THC - págs. 12/16).

As circunstâncias da apreensão da droga foram descritas pela testemunha Nilton, agente penitenciário. Disse que estavam fazendo revista no pavilhão e encontraram vinte e um invólucros de entorpecente nos pertences do réu, o qual falou que a droga era dele. Foi quem realizou a revista, estava acompanhado de vários agentes. Tratava-se de procedimento de rotina. Na ala ficam cento e oito presos e a cela é destinada a seis, porém não se recorda se nessa data havia esse número na cela. Descreveu que retiram os presos e eles ficam aguardando do lado de fora, realizam a revista e perguntam ao preso caso encontrem algo suspeito. Também verificam se há algum documento ou carta em meio aos pertences. A droga foi encontrada nos pertences do réu, junto de cartas, carteirinha, roupas. A droga estava em um saquinho só, e o réu disse que era para uso pessoal dele. Os pertences estavam sobre a cama do réu. Não há câmera no local em que os presos dormem, apenas na área externa (págs. 139/140).

A testemunha Leandro Aparecido, agente penitenciário, disse que participou da apreensão da droga, que foi feita no pavilhão B, na ala de progressão, por volta das 16h. Os presos estavam de quarentena nesse pavilhão, pois estavam voltando de saidinha. Acompanhou procedimento de revista e viu quando outro funcionário encontrou o material apreendido nos pertences do réu. O réu confirmou que era dele a droga. Estava ao lado do funcionário que encontrou a droga, fazendo revista em lugar próximo e por isso não sabe dizer o local exato que encontrada a droga. Foi avisado pelo outro funcionário quando ele encontrou a droga. Os detentos estavam no pátio. No alojamento havia outros detentos, mas a droga foi encontrada na cama que era do réu, nos pertences dele, não sabendo especificar onde, pois outro funcionário foi quem a achou (págs. 139/140).

Interrogado, o réu disse que já foi preso por furto e roubo, e está respondendo a processo por tráfico. Morava na zona leste de São Paulo, estava desempregado, não é casado e não tem filhos. Em relação ao crime de que é acusado, disse que houve chamada para contagem de presos e todos saíram. Foi explicado o procedimento que ocorreria. Andaram em sua direção e afirmaram que droga encontrada no chão era sua. Negou que a droga fosse sua, porém funcionário falou que era para segurar. Foi ouvido depois de cinco dias, e um funcionário falou que não era para comentar nada daquilo para não ser prejudicado. Assinou o depoimento que já estava batido. Ficou sem entender como acharam droga em sua cama, pois a droga estava no chão, e não sabe afirmar se alguém colocou a droga lá. Não tem inimizade com ninguém, mas algum preso pode ter jogado a droga lá. Filmagens poderiam esclarecer. Não foi apresentada droga nenhuma. O funcionário Renato foi quem falou que achou droga em seus pertences. O diretor foi quem falou que a droga que estava no chão era sua. O funcionário Nilton estava a seu lado no momento que falaram que a droga era sua. Seus pertences ficavam na cama B-69, dentro da bolsa, no canto da cama. Dentro da bolsa havia roupas, lençol, coisas do uso do dia a dia, não tinha cartas (págs. 139/140).

Transposta a instrução processual, nota-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia. Essa negativa, contudo, destoa do conjunto probatório.

Com efeito, o agente penitenciário Nilton descreveu como ocorreu a localização da droga nos pertences do réu. Disse que estava acompanhado de outros agentes, foi quem realizou a revista, encontrou vinte e um invólucros de entorpecente nos pertences do réu, o qual falou que a droga era dele. Descreveu que para a realização da revista os presos são retirados do lugar e ficam aguardando do lado de fora, então os agentes realizam a revista e perguntam ao preso caso encontrem

algo suspeito. Afiançou que também verificam se há algum documento ou carta em meio aos pertences e que, no caso, a droga foi encontrada nos pertences do réu, junto de cartas, carteirinha, roupas (págs. 139/140).

No mesmo sentido o depoimento fidedigno da testemunha Leandro Aparecido, outro agente penitenciário que participou da apreensão da droga. Aludida testemunha afirmou que foi feita no pavilhão B, na ala de progressão, por volta das 16h, os presos estavam retornando de saídinha. Disse, ainda, que acompanhou procedimento de revista, viu quando outro funcionário encontrou o material apreendido nos pertences do réu e este confirmar que a droga era dele. Reportou-se ao fato de que no alojamento havia outros detentos, porém esclareceu que a droga foi encontrada na cama que era do réu, nos pertences dele (págs. 139/140).

Importante destacar que nada há nos autos a infirmar a palavra das testemunhas. Nesse contexto, seria um contrassenso o Estado desacreditar a palavra dos agentes que atuaram no cumprimento do dever e nos limites da legalidade. A esse respeito, transcrevo trecho de elucidativo acórdão:

“No caso vertente, inexistiu motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos agentes públicos inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisonar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um crime de tal gravidade a pessoa inocente, ainda mais se valendo desnecessariamente de certa quantidade e variedade de drogas, mesmo porque isso nenhum proveito lhes traria. A propósito, cale lembrar prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando, como no caso, noticiam em Juízo suas atividades no combate e repressão à criminalidade... Além disso, as circunstâncias da prisão, ocorrida durante “blitz” realizada na cela em que habitava o réu, ocasião em que encontrados sobre a cama dele tóxicos, “chips” de celular e caderno com anotações típicas de contabilidade de tráfico (laudo pericial - fls. 76/93) em meio a pertences do acusado e junto com carta e comprovante de depósito bancário que lhe pertenciam, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida quanto a lhe pertencer o tóxico e se destinar ele ao insidioso comércio.” (TJSP Apelação Criminal nº 1500218-84.2020.8.26.0411, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 22.8.2022)

A propósito, o próprio réu confirmou que seus pertences ficavam na cama B-69, exatamente aquela indicada no comunicado de evento 21/2022 (pág. 8).

Especificamente em relação a imagens registradas por câmeras existentes na unidade prisional, as quais, segundo o réu, poderiam esclarecer os fatos, observa-se que o agente penitenciário afirmou que há câmeras apenas na área externa (págs. 139/140). Afora isso, assinale-se que o diretor da unidade prisional informou não ter sido constatada situação atípica que reclamasse o armazenamento de imagens (pág. 83).

Outrossim, o modo como ocorreu a apreensão do entorpecente colide com a ilação de que outro preso poderia ter colocado a droga no local no qual encontrada. Isso porque iminentes à atuação dos agentes as cautelas para evitar esse tipo de evento. Nesse sentido, outro trecho do Acórdão já especificado

“Por outro lado, não prospera a alegação da defesa, no sentido de que algum detento desconhecido teria jogado os tóxicos na cama do apelante, porque, ao que é dado concluir dos depoimentos dos agentes públicos, a “blitz” foi realizada de surpresa e com toda cautela para evitar uma ocorrência dessa natureza.”

O delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas é de ação múltipla, conteúdo variado, que se consuma com a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. No caso, o réu mantinha em depósito, na penitenciária, para fins de fornecimento e

entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo maconha (40,30 gramas), de modo que não há se falar em desclassificação, sobretudo porque na Delegacia e em Juízo o réu negou a propriedade da droga (págs. 18 e 139/140), além de que a quantidade e as circunstâncias da apreensão não se coadunam com a condição apenas de usuário.

Veja-se, ademais, que não raro mesclarem-se no mesmo agente infrator as figuras do usuário e do traficante, preponderando a última, de maior gravidade.

Nesse contexto, aliás, também restou demonstrada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de regência, porquanto o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional - Penitenciária Valentim Alves da Silva.

Presentes, pois, os pressupostos para a responsabilização penal, passa-se à dosimetria da pena com atenção para as regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que o réu ostenta antecedentes desabonadores (autos 0103973-64.2013.8.26.0050 e 0103973-64.2013.8.26.0050 - págs. 108/121). Note-se que no caso de múltipla reincidência parte pode ser considerada a título de maus antecedentes. Além disso, o réu incorreu no crime retratado nos autos quando retornava de saída temporária, benefício que pressupõe bom comportamento. Assim, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, procedo ao aumento de 1/6 à pena, resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, agravo de 1/6 a pena em decorrência da reincidência, específica aliás (autos 0011336-46.2017.8.26.06355 - págs. 108/121), perfazendo a pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/2006, aumento a pena de 1/6, resultando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, arbitro o valor de cada dia-multa no mínimo legal. Anoto que diante da múltipla reincidência, inclusive específica, não é aplicável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos das regras de individualização da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis, haja vista o tempo de pena, maus antecedentes e reincidência (Código Penal, artigos 44 e 77).

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno JEFFERSON FELIPE DA SILVA FERRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006, a ser atualizado.

O réu está respondendo solto a este processo (preso por outro) e assim poderá interpor eventual recurso.

Incinere-se quantidade de substância entorpecente que tenha remanescido, com

atenção para o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e o artigo 525 das Normas de Serviço.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do CPP, uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímem-se.

Garça, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA